

1500169-58.2022.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Simone Rodrigues Valle

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/09/2022

... podendo ficar configurado o delito de tráfico de drogas, ainda que o agente não tenha sido surpreendido praticando atos de comércio, como no presente caso, que o réu foi acusado de praticar o crime de tráfico de drogas na modalidade guardar e manter em depósito.

Cabe ressaltar que eventual carência financeira não caracteriza estado de necessidade capaz de legitimar a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

2ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista - SP - cep 12903-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500169-58.2022.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500169-58.2022.8.26.0545

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ GUSTAVO PROCACINO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Simone Rodrigues Valle

Vistos.

LUIZ GUSTAVO PROCACINO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. com artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06.

Consta da denúncia que, no dia 11 de fevereiro de 2022, no período da manhã, na Voluntário Valter Scaglione, 77, Jardim Das Laranjeiras, nesta Cidade e Comarca de Bragança Paulista, o acusado guardava consigo para fornecimento, venda ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiros, 180 pedras de crack, pesando 30g (trinta gramas), droga/entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O acusado foi notificado (fls. 111), e ofereceu defesa prévia às fls. 116/119, juntando documentos de fls. 120/128.

Após, a denúncia foi recebida às fls. 133/134.

Durante a audiência de instrução, inicialmente, o Ministério Público requereu o aditamento da denúncia, informando que houve erro material quando da inclusão do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, mantendo-se apenas o artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. O aditamento foi recebido e, após, foram ouvidas duas testemunhas

comuns e uma testemunha de defesa. Ao final, o réu foi interrogado (fls. 152). Encerrada a instrução, o Ministério Público se manifestou oralmente, oportunidade em que requereu a procedência da ação. Manifestou-se acerca da dosimetria da pena, requerendo o aumento da pena-base pela quantidade de drogas, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão. Ao final, requereu a fixação de regime inicial semiaberto.

A Defesa, por sua vez, apresentou memoriais a fls. 153/170. Requereu a improcedência da ação, absolvendo-se o acusado, nos termos do artigo 386, inciso VI, do CPP, reconhecendo-se a excludente de ilicitude do estado de necessidade. De forma subsidiária, manifestou-se acerca da dosimetria da pena, reconhecendo-se as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Requereu, ainda, o reconhecimento do tráfico privilegiado, bem como a aplicação do art. 41 da Lei de Drogas. Ainda na terceira fase da dosimetria, requereu o reconhecimento da causa de diminuição do artigo 24, §2º, do Código Penal. Ao final, requereu a fixação do regime aberto. Juntou documentos de fls. 171/182.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito de tráfico encontra-se totalmente demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 10/11, auto de exibição e apreensão às fls. 13, pelo laudo de constatação preliminar de fls. 14, pelo documento de fls. 17/18, pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 88/90), que apontou resultado positivo para cocaína nas substâncias entorpecentes apreendidas na ocasião, bem como pela prova oral produzida nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A autoria, por sua vez, restou comprovada.

Na fase policial, o acusado confirmou que estava guardando as pedras de crack em sua residência para um traficante que conheceu, porém, não quis declinar o nome por temer por sua segurança e de sua família. Disse que tomou essa atitude por estar em dificuldade financeira, já que está desempregado. Recebia do traficante a importância semanal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) semanais. Por fim, negou realizar comercialização de entorpecentes, afirmando que apenas guardava a droga (fls. 08).

Em juízo, confessou a prática delitativa. Disse que estava passando por muito dificuldade financeira. Não conhecia os policiais. Estava guardando a droga para um traficante, tendo recebido o valor de R\$200,00.

Hamilton de Souza Júnior, policial civil, declarou que possuíam informações da prática de tráfico pelo réu. Foram feitos trabalhos preliminares e havia movimentação suspeita na residência do acusado. Foi solicitado o mandado de busca no local e encontraram os entorpecentes, sendo 180 pedras de crack. O réu disse que apenas guardava a droga, no entanto, o acusado não forneceu nenhuma outra informação. Não se recorda se havia outras pessoas na residência. Relatou que o próprio acusado indicou o local onde estavam as drogas, que estavam escondidas embaixo do colchão. Não se lembra o valor que o réu disse receber por guardar o entorpecente, mas que ele recebia um valor semanal. Relatou que as informações que possuíam é de que o réu era ativo na venda dos entorpecentes. Não conhecia o acusado. Por fim, afirmou que o réu disse que estava desempregado.

No mesmo sentido o depoimento de Marcos Ely Barreto, também policial civil. Acrescentou que tinham denúncias acerca do local, afirmando que não havia indicação de nenhum nome. Passaram a fazer diligências no local e constataram um movimento diferenciado, razão pela qual solicitaram o mandado de busca. Foi o acusado quem recebeu os policiais e alguns familiares. O acusado indicou o local em que estavam as drogas, contabilizando 180 pedras de crack. Recorda-se de que o acusado disse estar passando por dificuldades financeiras. Afirmou que o réu disse que guardava a droga para um traficante, recebendo o valor de R\$ 250,00 por semana, no entanto, não quis indicar o nome do suposto traficante, com medo de represálias. Não conhecia o acusado.

Neide do Prado, testemunha de defesa, disse que é vizinha do acusado, residindo na casa da frente. Não tem conhecimento sobre o cumprimento de mandado de busca na casa do réu e nem das drogas. Não via movimentação de pessoas estranhas no local.

Pela prova oral produzida, verifica-se que a autoria do crime de tráfico restou comprovada.

Inicialmente, anoto que quanto ao depoimento do policial, na qualidade de agente público, possui fé pública, gozando da presunção relativa de veracidade, qualidade essa que não foi afastada pela Defesa.

Ademais, nada indica que o policial tenha criado alguma situação para acusar falsamente o acusado, não havendo nos autos qualquer elemento que comprove a implantação de drogas.

Registre-se, ainda, que a jurisprudência dominante tem se inclinado para admitir que os testemunhos de policiais, quanto aos atos de diligência, prisão e apreensão, devem merecer credibilidade desde que não evidenciada a má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público, o que não se verifica na hipótese dos autos.

A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que:

"A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita." (RTJ68/64).

E ainda:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal." (HC nº 74.608-SP/STF).

No caso dos autos, o acusado confessou em juízo que guardava os entorpecentes em sua residência, afirmando que estava passando por dificuldades financeiras.

A versão do acusado foi corroborada pelas testemunhas comuns ouvidas, que confirmaram o encontro da droga no local.

Assim, não restam dúvidas da prática delitiva.

Destaque-se que o artigo 33 da Lei nº 11.343/06 descreve condutas variadas, podendo ficar configurado o delito de tráfico de drogas, ainda que o agente não tenha sido surpreendido praticando atos de comércio, como no presente caso, que o réu foi acusado de praticar o crime de tráfico de drogas na modalidade guardar e manter em depósito.

Cabe ressaltar que eventual carência financeira não caracteriza estado de necessidade capaz de legitimar a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição nos termos pretendidos pela Defesa, bem como em eventual redução da pena.

Dessa forma, imperiosa, pois, sua condenação pelo crime do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Resolvido o mérito, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena não verifico circunstâncias judiciais que justifiquem a elevação da pena acima do mínimo legal, motivo pelo qual fixo a pena em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa no valor unitário mínimo legal.

Ainda na primeira fase, não há que se falar em aumento em razão da quantidade/variedade das drogas, pois a quantidade não é significativa a justificar o aumento nessa fase, totalizando 30 gramas de entorpecente.

Na segunda fase, verifico que se trata de réu com idade inferior a 21 anos na data do fato. Também reconheço a atenuante da confissão, porém, impossível a diminuição da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, verifico como recomendável seja aplicada a causa de diminuição contida no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, principalmente porque essa causa de diminuição da pena subsume-se à situação do acusado em questão (primário e não se vê a existência de antecedentes efetivos para justificar o impedimento dessa benesse, sem, também, qualquer demonstração de que se dedica à atividade criminosa ou integre organização criminosa), motivo pelo qual ele faz jus à redução de 2/3.

Assim, estabeleço a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, tornando-a definitiva por não encontrar nenhuma outra circunstância modificadora aplicável. Em que pese as alegações da defesa, não que há que se falar em aplicação do artigo 41, da Lei de Drogas.

Para a aplicação do referido artigo, conhecido como "delação premiada" necessita de uma colaboração efetiva nas investigações por parte do acusado, o que não é o caso

do acusado, já que o réu sequer identificou o nome do suposto traficante que pediu para que ele guardasse os entorpecentes em sua residência.

Nesse sentido já se manifestou o E. TJ/SP:

"APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (Artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06) RECURSO DEFENSIVO [...] DELAÇÃO PREMIADA - Inviável a redução da reprimenda pela aplicação da delação premiada, quando não preenchidos os requisitos previstos no art. 41 da Lei nº 11.343/06. [...] Anote-se que o art. 41 da nova lei de drogas menciona requisitos cumulativos para a aplicação da especial causa de diminuição e pela leitura do r. artigo, tem-se que é necessário que a colaboração possa ter efetividade para o desmantelamento de quadrilha ou bando criminoso, ou mesmo para a identificação de outro traficante, possibilitando que se possa oferecer denúncia e processamento do coautor. Desta feita, não há subsídios que apontem que a delação feita pelo apelante tenha se tornado objeto de investigação. Destaco que, no momento da abordagem, seu comparsa conseguiu fugir e o apelante em nada colaborou para sua identificação ou captura." (TJSP; Apelação Criminal 1500713-03.2018.8.26.0540; Relator(a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/11/2019; Data de Registro: 18/11/2019) (gn.)

Na hipótese, não houve qualquer colaboração por parte do réu para descoberta de eventual fornecedor ou outros colaboradores. A mera indicação do local de armazenamento dos entorpecentes, sem maiores esclarecimentos, não é suficiente para o reconhecimento da referida causa de diminuição de pena. Assim, não faz o acusado jus ao referido benefício.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, anteriormente, ao tratar de casos envolvendo o tráfico de entorpecentes, sempre entendi, em atenção ao disposto no art. 5º, XLIII, da CF, a integral aplicação dos rigores da Lei dos Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/90), a qual determina a imposição do regime inicial fechado (art. 2º, § 1º, com redação dada pela Lei nº 11.464/07), e da Lei nº 11.343/06, que veda a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, caput).

No entanto, ressalvada minha convicção pessoal, é necessário levar em consideração que, no âmbito dos Tribunais Superiores, em relação ao tráfico privilegiado, a Jurisprudência se consolidou para diferenciá-lo do tráfico em sua forma fundamental, tratando-o como delito não assemelhado a hediondo, sempre que preenchidos os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Nessa ordem de ideias, o Plenário do E. STF, ao julgar o HC nº 118.533/MS, em 23/06/2016, decidiu que: "O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos". Em vista deste precedente, a 3ª Seção do C. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, por unanimidade acolheu a tese vitoriosa no STF, revisando o entendimento até então firmado com o enunciado nº 512 daquela Corte, atualmente cancelado (Pet nº 11.796/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe 29/11/2016).

Importante destacar, em tempo, as decisões do E. STF que em caráter incidental declararam inconstitucionais, por afrontarem a individualização da pena, tanto a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os crimes hediondos e equiparados (HC nº 111.840/ES, j. 27/06/2012), quanto a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos da Lei de Drogas (HC nº 97.256/RS, j. 01/09/2010), com a consequente promulgação da Resolução nº 5 de 2012 pelo Senado Federal, suspendendo a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Embora proferidas em processos individuais, sem eficácia vinculante, essas decisões da Corte Suprema devem ser observadas, em nome da segurança jurídica e na busca da uniformidade na resolução de conflitos.

Sob essas premissas, passo a analisar o caso dos autos, tendo como objetivo o apenamento proporcional às condições pessoais do infrator e das circunstâncias específicas do comércio ilícito por ele desenvolvido, afastada a hediondez do delito e suas consequências.

O presente caso, enfim, versa sobre a apreensão de droga, que nos termos do laudo pericial pesava aproximadamente 30 gramas, na posse de indivíduo primário, com idade inferior a 21 anos, confesso, sem provas de conexão com as organizações criminosas ou traficância habitual.

Consequentemente, revendo posicionamento anterior e cedendo à orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores, fixo o regime ABERTO para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos moldes do art. 33, § 2º, "c", do CP.

Ainda, porque presentes os requisitos correlatos, em atenção ao quantum de pena e a primariedade do réu, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, na forma do art. 44, § 2º, parte final, do CP.

A primeira consistirá na prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública, indicando o Juízo das Execuções tanto o destinatário como a espécie de serviço a ser prestado pelo tempo da pena substituída; a segunda em prestação pecuniária no valor de 02 salários mínimos na época do fato em favor de entidade pública ou privada, com destinação social, também a ser designada pelo Juízo das Execuções. Isto posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal que o Ministério Público move contra LUIZ GUSTAVO PROCACINO DA SILVA, para, com base no artigo 33, caput, c.c. parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, CONDENÁ-LO à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa, substituída nos termos acima deliberados. Em razão da pena imposta, poderá o réu recorrer em liberdade.

Custas na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Bragança Paulista, 08 de setembro de 2022.

Simone Rodrigues Valle

Juíza Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA